


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020
TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: **0090048-93.2016.8.26.0050 – Controle 2016/001904**
 Classe – Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos**
 Documento de: **Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Origem:
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **WENDELL SANTOS NASCIMENTO**
 Data da Audiência: **08/03/2017**

Aos 08/03/2017, às 14:30h, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Capital, sob a presidência da MM(a). Juiz(a) de Direito Dr^a. Cristina Alves Biagi Fabri, comigo escrevente a seu cargo, afinal assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo em epígrafe. Estava presente o Ministério Público, na pessoa do Dr(a). Maria Claudia Andreatta Hirt; Presente(s) o(s) acusado(s) WENDELL SANTOS NASCIMENTO, neste ato representado pela Dra. Paula Hungria Aagaard, Defensoria Pública. Presente(s) a(s) testemunha(s) de acusação: André de Freitas e Renato Pereira.

Iniciados os trabalhos, foram inquirida(s) duas testemunha(s) arrolada(s) em comum (André e Renato), sendo o(s) acusado(s) interrogado(s). Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido, encerrando-se, portanto, a instrução criminal e passando-se aos debates. **Dada a palavra ao Ministério Público:** MM. Juíza, **WENDELL SANTOS NASCIMENTO**, qualificado a fl. 16, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, III, da Lei 11.343/06, porque no dia 25 de outubro de 2016, por volta das 21 horas e 30 minutos, na Rua Ricardo Dalton, altura do número 3, Anhanguera, **nas proximidades de estabelecimento de ensino**, nesta cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), **53,3g (cinquenta e três gramas e três decigramas) de cocaína, divididos em 45 porções e 20,7g (vinte gramas e sete decigramas) divididos em 51 “pedras” de crack**, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica. Está a materialidade do delito comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. autoria é certa, devendo ser atribuída ao acusado. Com efeito, a prova colhida sob o crivo do contraditório demonstra


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

que o réu efetivamente praticou tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos narrados na denúncia. Nesse sentido, relataram os policiais militares Andre de Freitas e Ricardo Pereira que estavam em patrulhamento de rotina e, quando o réu os viu, acelerou o passo. Suspeitaram desta conduta e o abordaram. Encontraram dentro da calça do réu uma sacola contendo cocaína e “crack”. Também encontraram com o réu a quantia de R\$80,00. O local da abordagem era no mesmo quarteirão de uma escola e era um conhecido ponto de venda de drogas. Quem revistou o réu foi o policial Ricardo. O réu confessou o tráfico. Em Juízo, o réu negou a acusação. Em sua defesa, disse que é tatuador e apenas comprou droga no local. Houve uma operação e foi “enquadrado” pelos policiais. No entanto, a versão escusatória do réu não merece acolhida. Os policiais confirmaram o encontro das drogas em poder do réu. É velha e conhecida a tese de que os depoimentos prestados por policiais acerca de crimes que ajudaram a desvendar, impediram sua consumação ou exaurimento não merecem crédito porque tais autoridades públicas teriam interesse em validar sua ação e, conseqüentemente, suas declarações devem ser vistas com reservas. Nada mais falacioso. O policial, civil ou militar, uma vez compromissado, é uma testemunha como outra qualquer e sua palavra merece crédito desde que não haja nada nos autos que a possa considerar como mentirosa. E, caso isso se verifique, sujeita-se o depoente às penas do falso testemunho, como qualquer outra testemunha. Conforme já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (**Apelação: 0037840-47.2010.8.26.0114. 7ª Câmara Criminal. Rel. Fernando Miranda. v. u.**): **“Vetusta e vazia, data venia, a objeção que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora, todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou algum outro qualificativo do testificante. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão de testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante”**. A quantidade de entorpecente, sua variedade e sua forma de acondicionamento, para pronta venda no varejo, bem como a apreensão conjunta de dinheiro, comprovam a finalidade de tráfico. Assim, comprovados os fatos narrados na


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

inicial, de rigor sua condenação. **Passo a analisar a dosimetria da pena.** Em primeira etapa, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes, já tendo sido condenada pela prática de tráfico de entorpecentes. Desta feita, é íntima a sua relação com a senda criminosa e com a narcotraficância, devendo ser majorada a pena-base. Ademais, é o réu reincidente, devendo a pena se aumentada. Por fim, na terceira etapa, cumpre ressaltar que não faz jus o acusado à incidência da regra prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, posto que é reincidente e que a quantidade de substâncias apreendidas, bem como o fato de já possuir outra condenação pelo mesmo delito, demonstram sua íntima ligação com a atividade criminosa, pela sua capacidade de organização, fazendo do tráfico sua profissão, não se tratando, portanto, de mero comerciante ocasional, pelo que não deve ser aplicada a causa de redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme precedentes do E. Tribunal de Justiça deste Estado (TJ/SP, AC 990.10.293847-6 e AC 993.08.034087-0). O regime, tratando-se de crime assemelhado a hediondo, deverá ser o inicial fechado, nos termos dos artigos 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 e 44, da Lei de Drogas, ambos não suspensos pela Resolução 5/12 do Senado Federal. Do exposto, requer o Ministério Público a procedência desta ação penal, condenando-se o réu nos termos da denúncia. **Dada a palavra à Defesa:** MM. Juíza, Ao término da instrução, verifica-se que não foram produzidas provas aptas para a condenação. Assim, a ação penal deve ser julgada improcedente. Em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o réu negou os fatos descritos na denúncia. Afirmou que é tatuador e após trabalhar passou em uma praça para comprar maconha para uso próprio. Vários policiais apareceram e tentou sair, pois estava foragido. Em seu poder havia R\$ 780,00. Negou estar na posse de sacola contendo drogas. Afirmou que estava na posse de uma paranga de maconha, para seu uso. A negativa do réu é elemento hábil a ensejar uma absolvição e não foi refutada pelas frágeis provas produzidas. A prova acusatória é frágil, restrita aos depoimentos prestados por dois policiais militares, justamente os policiais que efetuaram a prisão do acusado. Afirmaram André de Freitas e Renato Pereira que efetuavam patrulhamento quando decidiram abordar o acusado, em cuja posse, escondido na cueca, foi encontrada uma sacola com entorpecentes. Contudo, divergiram os policiais em aspecto essencial da abordagem, pois afirmaram que as drogas estavam sob a cueca do réu, ao passo que, durante o inquérito


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

policial, afirmaram que a sacola estava em suas mãos. Não bastasse, é certo que nenhuma testemunha estranha aos quadros policiais foi inquirida em juízo a fim de confirmar os fatos. Acrescente-se que os policiais não viram nenhum ato típico de mercancia, tudo a demonstrar a inocência do réu. Pretende a Defesa alegar que os policiais, pela própria natureza das atividades que exercem, têm o maior interesse na legitimação de sua conduta profissional, não podendo ser descartada a hipótese de que sua parcialidade em Juízo possa prejudicar o acusado. De um lado, é certo que não é possível concluir-se pela sua suspeição pela simples condição funcional; de outro, se não é suspeito, tem eles todo o interesse em demonstrar a legitimidade dos atos praticados, do acerto da investigação realizada, não podendo prevalecer sem o cotejo com outros elementos de prova. Nenhuma outra testemunha foi inquirida em juízo, restando frágil o conjunto probatório. Diante do exposto, outra solução não espera a Defesa que não a prolação de um édito absolutório, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso, contudo, Vossa Excelência não entenda pela absolvição, o que se admite apenas por hipótese, requer-se, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento da causa de aumento de pena descrita na denúncia, pois não se demonstrou o dolo do agente em atingir os alunos da instituição, tampouco se comprovou que a escola estava em funcionamento no horário descrito na denúncia (21h30min); se o entendimento versar no sentido da condenação pelo art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06, requer-se a redução *máxima* da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Deixar de aplicar a referida minorante exclusivamente em razão da recalcitrância significaria incorrer em ofensa aos princípios da proporcionalidade e do *non bis in idem*. Isso porque a não aplicação da causa de diminuição acarretaria a seguinte situação: se primário, ao réu seria atribuída uma pena de 1 ano e 8 meses de reclusão; já, se reincidente, ser-lhe-ia arbitrada pena superior a 5 anos. Ora, é evidente a desproporcionalidade das sanções, atentando-se, em especial, ao fator de discriminação adotado (reincidente). Se para os demais crimes há, normalmente, em razão da reincidência, uma diferença, entre primários e reincidentes, de apenas 1/6 na pena, não há razão lógica para que apenas no tráfico se estabeleça um desnível superior a 300%. Ademais, entendendo-se pela inaplicabilidade do dispositivo acima, estaria uma mesma circunstância fática (reincidência) servindo, a um só tempo, como agravante e


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

causa impeditiva da diminuição, representando, assim, duplo apenamento em flagrante infração ao princípio do *non bis in idem*. Desta feita, o redutor não poderá deixar de ser aplicado em seu patamar máximo. Reduzida a pena, requer-se, em atendimento ao princípio da individualização da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, já que não se trata de reincidente específico (art. 44, §3º do CP) ou o sursis da pena, bem como a fixação de regime aberto ou semiaberto para início de cumprimento da pena (art. 33, §2º, “c” do CP e súmula 269 do C. STJ). Nesse sentido, vale destacar a Resolução n. 05 de 2012 do Senado Federal que suspende a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, possibilitando, portanto, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos no crime de tráfico de drogas: “O Senado Federal resolve: Art. 1º É suspensa a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004o06/2006/Lei/L11343.htm#art33>, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS”; requer-se seja considerado o tempo de prisão cautelar para se determinar o regime prisional (artigo 387 CPP); por fim que lhe seja autorizado que aguarde em liberdade o trânsito em julgado. **A seguir foi proferida a seguinte sentença:** Vistos, **WENDELL SANTOS NASCIMENTO**, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/06, porque no dia 25 de outubro de 2016, por volta das 21 horas e 30 minutos, na Rua Ricardo Dalton, altura do número 3, Anhanguera, nas proximidades de estabelecimento de ensino, nesta Capital, trazia consigo, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento de terceiros(tráfico), 53,3 g de cocaína, divididos em 45 porções e 20,7g divididos em 51 pedras de crack, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como a quantia em dinheiro de R\$ 80,00. Notificado nos termos do artigo 55, “caput” da Lei nº 11.343/06 (fls.160), o acusado apresentou defesa prévia por escrito (fls. 165/167). A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2017 (fls. 172). Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado. Os debates foram realizados. É a síntese do necessário. **DECIDO.** A ação penal é procedente. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/06), no boletim de ocorrência (fls. 09/11), no auto de exibição e apreensão (fls. 12), no auto de constatação (fls. 15/16), bem como no exame químico toxicológico (fls.139/140). A autoria restou incontroversa. O réu, no interrogatório, negou a acusação, dizendo estar no local dos fatos apenas para fumar maconha. Alegou estar sendo injustamente acusado. Em que pese a versão do acusado, a prova produzida nos autos é forte e escoreita em sentido contrário. Vejamos. Os policiais militares André e Renato, que participaram da abordagem do acusado, disseram ter sido ele abordado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, estando na posse de uma sacola, contendo “cocaína” e “crack”, além de dinheiro. Informaram a existência de uma escola perto do local dos fatos, bem como afirmaram ter o réu admitido a mercancia. Consoante se infere dos depoimentos colhidos, não pairam dúvidas de que o réu estava praticando tráfico ilícito de entorpecentes, quando surpreendido pelos policiais, não havendo explicação outra, a não ser àquela contida na denúncia, para o encontro de várias porções e tipos de entorpecentes em seu poder. A corroborar a conclusão supra, temos o encontro do dinheiro, fruto da mercancia; o local da abordagem, conhecido como ponto de tráfico de drogas; bem como a confissão informal aos policiais, que não pode ser desprezada. Ademais, razão alguma teria as testemunhas policiais para acusar injustamente pessoa inocente, que sequer conheciam. Cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconseqüente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a juízo, com intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, mesmo porque seria um contra-senso que o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando chamados à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não lhes emprestasse a credibilidade necessária. Sendo assim, diante da harmonia e coerência das provas amealhadas durante a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

instrução do feito, de rigor a prolação do édito condenatório. Há que se reconhecer a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei de Drogas, eis que o acusado estava no exercício da mercancia nas imediações de escola, pouco importando, para tanto, a comprovação de ter sua conduta atingido alunos da instituição ou estar ela em funcionamento. Passo a dosimetria da pena. Na primeira fase de fixação da reprimenda, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, pelo que aumento a pena em 1/6, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no unitário mínimo, ante a condição econômica do acusado. Diante da reincidência, aumento a pena em mais 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal. Presente a causa de aumento de pena, majoro a reprimenda em mais 1/6, totalizando 07(sete) anos, 11(onze) meses e 08(oito) dias de reclusão e pagamento de 813(oitocentos e treze) dias-multa, no mínimo legal. Não havendo outros fatores modificativos, torno definitiva a reprimenda acima imposta. Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a acusação para **CONDENAR WENDELL SANTOS NASCIMENTO**, com qualificação nos autos, a cumprir a pena de 07(sete) anos, 11(onze) meses e 08(oito) dias de reclusão e pagamento de 813(oitocentos e treze) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06. Quanto ao regime prisional, sendo reincidente, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Eventual alteração do regime prisional ficará a cargo do juízo da execução. Pelo mesmo motivo, qual seja, recidiva, impossível a redução da pena nos termos do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, bem como a aplicação do disposto nos artigos 44 e 77 do Código Penal. O réu está preso e assim deverá permanecer caso queira recorrer desta sentença, pois não faz jus a qualquer benefício legal, por medida de garantia da ordem pública, pois praticou crime gravíssimo, que vem intranquilizando a sociedade, gerando clamor público. Recomende-se o réu no cárcere onde se encontra. Transitada esta em julgado, tenha o réu o seu nome lançado no rol dos culpados. Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD, bem como determino a incineração do entorpecente apreendido, providenciando-se o necessário. Dou a presente por publicada em audiência e as partes por intimadas. Registre-se e cumpra-se. NADA MAIS. Lido e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

**Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP
01133-020**

achado conforme, vai devidamente por mim, ____ esc., Heloise Mignon Branco Rodrigues, que digitei e subscrevi.

MM(a). Juiz(a):

Ministério Público:

Dr(s). Defensor(es):

Acusado(s):